Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Conclusão

Aos 09/04/2019 09:11:31 foram estes autos conclusos ao Dr. Eduardo Magrinelli Júnior, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Naviraí-MS.

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0807473-77.2018.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autora:** Mikaelly Fernandes Ramalho e **Réu:** Município de Naviraí

Mikaelly Fernandes Ramalho, criança representada pela genitora Suzana Fernandes dos Santos, move a presente **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada** em desfavor do **Município de Naviraí,** qualificado, dizendo, em resumo, que tem aproximadamente dois anos e dez meses de idade e necessita de leite especial, zero lactose, pois possui intolerância à lactose, apresentando baixo pessoa para a sua idade. Afirma que necessidade de 11 litros de leite ao mês, pois consome três mamadeiras de 120 ml por dia. Afirma não ter condições de adquirir com seus próprios recursos o leite que necessita e que também não conseguiu obtê-lo administrativamente do requerido. Fez demais requerimentos de praxe e juntou documentos às f. 15-25.

Antecipação dos efeitos da tutela deferida às f. 32-35, mediante prévia consulta à Câmara Técnica em Saúde (Cates) de f. 27-31.

Citado, o Município apresentou contestação às f. 40-59, argumentando, em síntese, que não há receita pública para custear a pretensão da Autora, já que ela não consta da lista básica de medicamentos oferecidos pelo SUS e, portanto, o Município não pode atender a demanda. Acrescentou que o Município não pode ser considerado o salvador universal e que o acolhimento da pretensão do autor implicaria violação aos princípios da isonomia, reserva do possível e separação dos poderes, configurando, em suma, indevida ingerência da atividade administrativa. Juntou documentos às f. 60-65.

Réplica às f. 69-81, ocasião em que a parte autora também especificou provas.

O Município, à f. 84, informou não ter outras provas a produzir, opinando pelo julgamento antecipado da lide.

Foi interposto agravo de instrumento da decisão que concedeu a tutela provisória, porém o recurso restou improvido (f. 86-101).

É o relatório no essencial.

Decido.

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644
Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3924-4211, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807473-77.2018.8.12.0029 e código lfwQYA9J.

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, sequer foi requerido por alguma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º que "A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício." E, no artigo 7.º, que "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até despiciendas se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado enventualmente através de entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3924-4211, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807473-77.2018.8.12.0029 e código lfwQYA9J.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).

É inequívoca a responsabilidade do réu em fornecer assistência à saúde a quem dela necessitar, o que inclui o oferecimento de medicamentos, exames, consultas, procedimentos cirúrgicos e o leite especial de que a Requerente necessita para a garantia de sua saúde.

A necessidade do atendimento já restou examinada na decisão que concedeu a tutela provisória, cujos fundamentos restaram inalterados por fatos supervenientes e, ademais, foi confirmada em segunda instância.

Verificou-se que a hipótese dos autos versa sobre o fornecimento de leite especial, sem lactose, uma vez que a Requerente, criança de tenra idade (com cerca de três anos e meio atualmente), possui intolerância à lactose e sua família não tem condições de arcar com o alimento na quantidade necessária.

Observa-se que a Requerente, diante da quantidade inadequada de leite consumido, apresenta baixo peso para idade, necessitando de "maior aporte calórico e evitar a perda maior de peso" (f. 18).

Além disso, o NAT foi favorável ao pedido apresentado, confirmando a necessidade e a urgência da Requente quanto ao recebimento do leite especial para nutrição adequada (f. 30):

"**XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.**
Considerando que a paciente está sendo atendida pela rede pública de saúde;
Considerando que não foram apresentados exames complementares;
Considerando a Política Nacional de Alimentação de Nutrição;

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3924-4211, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807473-77.2018.8.12.0029 e código lfwQYA9J.

Considerando que leite sem lactose não é disponibilizado pelo SUS no Estado do Mato Grosso do Sul;
Considerando decisão de membros da CONITEC, pela incorporação das fórmulas nutricionais para necessidades dietoterápicas específicas indicadas para crianças com intolerância à lactose;
Considerando diagnóstico nutricional de baixo peso para idade;
Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido leite sem Lactose, sem distinção de marca a ser adquirida, 11 litros/mês."

Tendo em vista que o leite solicitado foi receitado por profissional que atende no serviço de saúde público, que certamente tem conhecimento das opções disponibilizadas pela rede pública e daquelas que sejam mais adequadas ao tratamento médico, é o caso de procedência do pedido. Em caso similar, já decidiu o E. TJMS:

> APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – **LEITE ESPECIAL – MENOR ALÉRGICA A LEITE DE VACA E SOJA – PARECER DO NÚCLEO DE SAÚDE FAVORÁVEL** – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todos os entes federativos são integralmente responsáveis pela saúde da população, não cabendo a qualquer deles imputar ao outro o dever de promover ações tendentes ao resguardo da saúde do cidadão necessitado. O leite especial foi receitado pelo profissional que atende no serviço público de saúde, sendo que também o Núcleo de Apoio Técnico concluiu favoravelmente ao pleito, confirmando a necessidade do fornecimento para nutrição adequada do infante, portadora de alergia a leite de vaca e soja. (**TJMS**. Apelação n. 0803378-09.2015.8.12.0029, Naviraí, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 22/02/2017, p: 23/02/2017). - Grifei

Saliento, ainda, a Constituição Federal, em especial no art. 227, assegura à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, colando-a salvo de toda forma de negligência, *in verbis*:

> Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

E não há falar que o atendimento somente deverá ser fornecido quando houver risco de morte, pois a Constituição garante a saúde em suas mais variadas acepções, inclusive como um processo de "bem-estar" geral ou social. É evidente que todos têm o direito de viver de forma digna e com saúde, o que está intrinsecamente ligado à garantia de recebimento de atendimento adequado pelo serviço universal e integral que deve ser prestado pelo Estado em suas diversas esferas.

Não se trata de judicializar políticas públicas, mas de garantir o

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3924-4211, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807473-77.2018.8.12.0029 e código lfwQYA9J.

atendimento adequado a quem dele necessita. É fazer com que o Estado (sentido amplo) cumpra seu papel, cumpra as políticas públicas com as quais deveria estar comprometido, cumpra os fins do Estado estabelecidos na Constituição.

No que toca à imposição de multa, é ela perfeitamente possível, conforme reiteradamente os tribunais superiores têm decidido, não tendo a Fazenda Pública prerrogativa de não se sujeitar a referida técnica executiva.

Ante o exposto, confirmando neste momento a antecipação dos efeitos da tutela, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que o **Mikaelly Fernandes Ramalho**, qualificada, fez em desfavor do **Município de Naviraí**, qualificado, para o fim de determinar ao réu que, por meio de seu órgão executor competente, forneça à Requerente **leite especial zero lactose,** na quantidade necessária para sua adequada nutrição e mediante a apresentação de receituário médico e/ou nutricional, durante todo o tratamento, no prazo de 20 (vinte) dias após a solicitação, sob pena de incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 30(trinta) dias.

Sem custas, *ex vi legis*. Sem honorários.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí, **datado e assinado digitalmente.**

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3924-4211, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807473-77.2018.8.12.0029 e código lfwQYA9J.